

אמנות ההתנגדות: מבט משווה על התנגדות לשאלות הצד שכנגד

מאת: משה סרוגוביץ'

מבוא

"Objection!". אין מילה אחרת שמעבירה את מהותו של מקצוע עריכת הדין, במיוחד בתחום הליטיגציה, באופן כל כך מתומצת ומרגש. כל עורך דין ישראלי, במיוחד מי שגדל על תמהיל סדרות המשפט האמריקניות ששודרו בישראל, החל מ"פרקליטי אל איי" (L.A. Law) בשנות ה-80 ועד ל"אישה הטובה" (The Good Wife) כיום, דמיין את עצמו לפחות פעם אחת עומד על רגליו בבית המשפט וצועק "Objection!". והנה, מה גדולה תהיה אכזבתו של אותו עורך דין ישראלי צעיר שקיבל זה עתה את רישיונו, כאשר לאחר מספר דיונים בבית המשפט בישראל יבין כי בניגוד למה שראה כל חייו בסדרות הטלוויזיה האמריקניות, הדיון בבתי המשפט בישראל דל בהתנגדויות עד מאוד. כה דל שעד שנראה לעיתים כי ההתנגדות היחידה המוכרת בבית משפט ישראלי היא "חברי מטעה את העד", התנגדות שאחריה מתחיל בדרך כלל ויכוח מתיש בשאלה מאיזה נקודה בדיוק יש להקריא לעד מהודעתו הכתובה כדי לא להוציא דברים מהקשרם.

נראה כי אכן אלה הם פני הדברים, ולא רק מצפייה בסדרות משפט בטלוויזיה. במסגרת דיני הראיות וכללי ניהול המשפט הנהוגים ברוב המדינות בארה"ב¹ מוכרות עילות רבות יותר להתנגדות לשאלות הצד שכנגד מאשר במשפט הישראלי.

ייתכן והסיבה לכך היא שיטת המושבעים. משפטים פליליים בעבירות שאינן פוטות מתנהלים בארה"ב בפני חבר מושבעים, מכוח זכותו החוקתית של הנאשם.² בישראל, לעומת זאת, המשפט מתנהל בפני שופט מקצועי המשמש גם בתור קובע העובדות והמכריע במהימנות עדים (עניין השמור בדרך כלל לחבר המושבעים), וגם בתור מי שמיישם את הדין על העובדות שנקבעו.³ עניין זה יכול להסביר את העדרה של מסורת מושרשת של התנגדויות במשפט הישראלי, שכן ההנחה, אותה בתי המשפט

שוקדים לבסס ולפתח במשך השנים, היא ששופט מקצועי יידע לברור בעצמו את הבר מן המון ולכן אין צורך להתנגד לכל שאלה שאינה מנוסחת כראוי.⁴ מעבר לכך, נראה כי בית המשפט נוטה לראות התנגדויות מצד עורכי הדין כהסחת דעת מיותרת אשר מכבידה על עבודתו שלא לצורך.⁵ אני סבור שזו תפישה מוטעית. להתנגדות שבמקומה יש לעיתים רווחים טקטיים ברורים. התנגדות שכזו יכולה לקטוע בצורה לגיטימית קו חקירה מוצלח של היריב, להוציא אותו מריכוז, לפגוע במומנטום של חקירתו ולאפשר לעד זמן לארגן את מחשבותיו ותשובותיו. אך חשוב מכך, שאלות שאינן מנוסחות כראוי עלולות להביא לתשובות שאינן קבילות או שאינן רלוונטיות, להטעות את העד ואף להסיט ממסלולו גם שופט מקצועי, ולא רק חבר מושבעים, לעבר קביעות עובדתיות או קביעות מהימנות שגויות או לא מבוססות. בנוסף, דיני הראיות נוטים להתנוון כאשר אין חבר מושבעים. תופעה זו מוכרת בישראל, בין היתר, באמצעות המעבר מקבילות למשקל, אשר פירושו בסופו של יום, הרבה פחות התנגדויות לקבילות ראיות ולשאלות לא ראיות וויכוח חסר כללים וחסר הכוונה על שאלת משקלן של אותן ראיות.⁶

מטרתה של רשימה קצרה זו היא להציג בפני עורך הדין הפלילי הישראלי את ההתנגדויות העיקריות הקיימות במשפט האמריקני ולבחון את השאלה האם ניתן להעלות התנגדויות אלה גם במסגרת דיון בבית משפט ישראלי. הרשימה תבקש לברר האם ההתנגדות מתאימה הן לדין הישראלי הכתוב עלי ספר והן למנהג המשפטי המקומי, כלומר לרשימת הכללים הלא כתובים אשר לפיהם מתנהל הדיון במשפט הפלילי הישראלי.

סיווג ההתנגדויות במשפט האמריקני

נפתח את הדיון המשפטי בשאלת ההתנגדות לשאלות היריב

1 מנהל מחלקת מעצרים, הסניגוריה הציבורית מחוז הדרום. מוסמך למשפטים של אוניברסיטת מישין באן ארבור, ארה"ב. ברצוני להודות לחברי שקראו טיוטות מוקדמות של רשימה זו והעירו הערות חשובות, עו"ד אלעד גויגולד, עו"ד אשרת חנוך ועו"ד אביגיל ארד-אביעזר. תודה מיוחדת אני חייב לצוות עורכי מאמרי הסניגור, ד"ר ענת הורוויץ, ד"ר אלקנה לייס וכו"ד רענן גלעד, על הערותיהם המאירות ועל העריכה המצינית שתרמה רבות לנוסחה הסופי של רשימה זו. הדעות המובאות ברשימה וכל טעות שאולי השתרבה הן שלי בלבד.

2 ברשימה זו אתמקד במבט משווה על המשפט האמריקני בלבד, תוך התמקדות בדיון הפדרלי. כמובן שגם במדינות אחרות של המשפט המקובל בהן מתנהלים משפטים בפני חבר מושבעים קיימת תרבות מפותחת של התנגדויות לשאלות הצד שכנגד.

3 ראו: Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), Baldwin v. New York, 399 U.S. 66 (1970), Blanton v. City of North Las Vegas, 489 U.S. 538 (1989). בפועל, מיעוט ניכר מן המשפטים בארה"ב מתנהלים בפני חבר מושבעים עד להכרעת דין, כאשר למעלה מ-95% מן ההליכים מסתיימים בהסדרי טיעון. ראו, W. J. Stuntz, The Collapse of American Criminal Justice (2011), 7. הדיון בתופעה מרתקת ומטרידה זו חורג ממסגרתה של רשימה זו.

4 ראו ק' שפירא-אטינגר ור' שפירא, "כלל הפסלות הישראלי בשולי הלכת יששכרוב", **דין ודברים** ג' (תשס"ח), 427, 432-431. 5 לדיון מרתק בשאלת הבניית דמותו של השופט המקצועי באמצעות כללי פסלות שופט ראו: י' רוזן-צבי, "האם שופטים הם כבני אדם? כיוון דמות השופט בראי כלל הפסלות", **משפט וממשל**, ח' (תשס"ה), 49.

6 א' הרנון, **דיני ראיות**, חלק ראשון (תש"ל-1970), 35 (להלן: "הרנון").

7 שפירא-אטינגר ושפירא, לעיל הערה 4, **שם**.

8 חשוב לציין כי כל האמור ברשימה זו מתייחס אך ורק למשפט פלילי. אמנם דיני הראיות הינם זהים לגבי משפט אזרחי ומשפט פלילי, הן בארה"ב והן בישראל, אך סדרי הדין, המשפיעים לעיתים השפעה קריטית על דיני הראיות, שונים בתכלית. בנוסף, לכותב אין כל ניסיון מעשי במשפט אזרחי ולכן כל המבקש לגזור

בקשה למחוק את התשובה מן הפרוטוקול ולהורות לעד להשיב על השאלה כפי שנשאלה. דוגמא נוספת היא הרחבת חזית במקום שבו לא ניתן לעשות זאת. במשפט האמריקני הכלל הרווח הוא שהחקירה הנגדית מוגבלת לנושאים שעלו בחקירה הראשית או לנושאים הקשורים למהימנות העד,¹² ולכן שאלה החורגת מן ההגבלה הזו היא אינה במקומה ומהווה עילה להתנגדות. דוגמא נוספת הקיימת גם במשפט האמריקני וגם במשפט הישראלי מהווה הכלל לפיו החקירה החוזרת מוגבלת לשאלות בנושאים שעלו במסגרת החקירה הנגדית בלבד. לכן שאלה החורגת ממגבלה זו מהווה עילה להתנגדות.¹³

ברשימה זו אתמקד בעיקר בהתנגדויות לנוסח השאלה, אגע מעט בהתנגדויות הנוגעות לתזמון ורצף ובהתנגדויות הנוגעות ליסודות הראייה, ואמנע כאמור לחלוטין מדיון בהתנגדויות מהותיות, הנוגעות לתוכן הראייה. מכיון שהתנגדויות אלה הן בבסיסן טענות משפטיות מתחום דיני הראיות, ולאור השוני הרב הקיים בין דיני הראיות בישראל לבין דיני הראיות הנהוגים במדינות השונות בארה"ב, בחרתי שלא לדון בהתנגדויות מהותיות ברשימה זו. זאת גם משום שמדובר בדיון שלא יאפשר גזירת מסקנות פרקטיות לעורך הדין המופיע בבית משפט בישראל וגם מפאת קוצר היריעה.

המקורות המשפטיים לביסוס עילה להתנגדות

המקורות המשפטיים המבססים את עילות ההתנגדות הם מגוונים. כאשר מדובר בהתנגדויות הנוגעות לתוכן הראייה, כלומר לקבילות של התשובה או לקבילות ראייה אחרת אשר צד מבקש להגיש לבית המשפט, הכללים המבססים את עילות ההתנגדות הם דיני הראיות. דיני הראיות קובעים מהי ראייה קבילה, מהי ראייה שאינה קבילה ומהם תנאי הסף לקבילות ראיות כאלה ואחרות. כאמור, רשימה זו לא תעסוק בהתנגדויות אלה שהן לא התנגדויות של ממש אלא טענות משפטיות לאי קבילותה של ראייה מסוימת המבוססות על דיני הראיות הרלוונטיים.

לעומת העושר היחסי של דיני הראיות, המבוססים היטב הן בדיון החקוק והן בפסיקה, המקורות המשפטיים להתנגדויות שלא נוגעות לתוכן הראייה מוגבלים יחסית, גם במשפט הישראלי וגם במשפט האמריקני.

במשפט הישראלי, פרק ה', סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 קובע, בין היתר, כי המשפט יתחיל בפרשת התביעה ויסתיים בפרשת ההגנה.¹⁴ סימן ו' לפרק זה קובע כי עד ייחקר לראשונה בידי בעל הדין שביקש את שמיעתו ואחריו רשא הצד שכנגד לחקור אותו בחקירה שכנגד. לאחר תום

בסיווג סוגי ההתנגדויות השונים. במשפט האמריקני נהוג לסווג את ההתנגדויות לארבעה סוגים: התנגדות לתוכן הראייה (המכונה לעיתים גם התנגדות מהותית⁹), התנגדות ליסודות (או לבסיס) הראייה, התנגדות לצורת (או נוסח) השאלה והתנגדות לתזמון ורצף.¹⁰

התנגדות לתוכן הראייה - התנגדות זו היא התנגדות לקבילות

התשובה. כלומר, לא השאלה היא הבעיה אלא קבילותה של התשובה לשאלה. התשובה עלולה להיות בלתי קבילה מכיוון שמדובר בעדות מפי שמועה שאינה קבילה לאמיתות התוכן, כי התשובה אינה רלוונטית ולכן אינה קבילה, משום שהתשובה חושפת מידע על אופי רע או מעשים שליליים קודמים של הנאשם שאינם קבילים בשלב ברור האשמה, ועוד. כלומר, יותר מאשר מדובר בהתנגדות, מדובר בטענה משפטית כי ראייה מסוימת אינה קבילה. למרות זאת, התנגדות זו יכולה וצריכה להיות גם התנגדות לשאלה עצמה, גם בטרם ניתנה תשובה, כאשר ברור מנוסח השאלה כי היא מתכוונת לחלץ מן העד תשובה שאינה קבילה כראייה.

התנגדות ליסודות (או לבסיס) הראייה - התנגדות זו גם היא

בבסיסה התנגדות לקבילותה של התשובה, יותר מאשר התנגדות לשאלה. מהותה של ההתנגדות היא שהראייה המוצעת אינה קבילה משום שלא הוכח תנאי מקדים הנדרש לצורך קבילותה. דוגמאות אפשריות לכך הן העדר אימות לאותנטיות של מסמך, העדר ראיות להיותו של העד מומחה אשר יכול להעיד עדות סברה, העדר הוכחת עובדה הנדרשת לצורך קביעה כי הראייה היא אכן רלוונטית להליך המשפטי ועוד.

התנגדות לצורת (או נוסח) השאלה - זו היא ההתנגדות

הקלאסית לשאלה בה תעסוק רשימה זו בעיקר. כאן ההתנגדות אינה מבוססת על קבילות הראייה המוצעת. כלומר, תשובתו של העד לשאלה עשויה בהחלט להיות קבילה ברגע שתינתן, אולם השאלה שנשאלה מנוסחת בצורה שאינה ראויה ולכן עליה להיפסל כשלעצמה ועל הצד השואל לנסח את שאלתו בצורה אחרת. התנגדות זו צריכה להיות מושמעת מיד לאחר סיום השאלה שכן אם העד יענה את תשובתו הקבילה לשאלה הלא ראויה, ההתנגדות תהפוך לחסרת רלוונטיות בהעדר טענות כנגד התשובה.¹¹

התנגדות לתזמון ורצף - התנגדות זו עניינה בכך שהשאלה

או התשובה איננה בלתי קבילה כשלעצמה, אלא שהתזמון שלה לא ראוי, כלומר היא מגיעה שלא בזמנה. כך לדוגמא, תשובה שאינה מהווה מענה לשאלה שנשאלה, היא כשלעצמה קבילה, אך היא איננה ראויה ולכן יכולה להוות בסיס להתנגדות במובן של

אמירות או מסקנות מרשימה זו וליישם במשפט אזרחי עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.

9 ראו: C. B. Mueller and L. C. Kirkpatrick, Evidence (5th Ed., 2012) (להלן: "מולר וקירקפטרק"), בעמ' 590-591.

10 בחלק זה של הרשימה התבססתי בעיקר על: Richard O. Lempert et al., A Modern Approach to Evidence: Text, Problems, Transcripts and Cases (4th Ed. 2011), 151-52.

11 מכאן נובעות לעיתים אמירות של שופטים וצדדים בדיונים כי "ניתן להתנגד לשאלה אבל לא ניתן להתנגד לתשובה." זוהי כמובן אמירה שנכונה רק בחלקה. בוודאי שניתן להתנגד לקבילותה של תשובה שאינה קבילה, אך לא ניתן להתנגד לתשובה קבילה רק כאשר השאלה מנוסחת בצורה שאינה ראויה. במקרה כזה אכן ניתן להתנגד רק לשאלה.

12 FRE, Rule 611 (b).

13 "קדמי, על סדר הדין בפלילים: חלק שני, הליכים שלאחר כתב האישום ב", (מהדורה מעודכנת, התשס"ט-2009) - (להלן: "קדמי"), עמ' 1582-1583. 14 סעיפים 156 עד 159 לחוק.

החקירה הנגדית, רשאי הצד שביקש שמיעתו של העד לחקור אותו שוב, בחקירה חוזרת.¹⁵ עוד קובע הסימן כי עדים מסוימים יחקרו בחקירה ראשית, על דרך של חקירה שכנגד: עד תביעה שלא נקרא להעיד, עד עוין ועד הגנה מטעם אחד הנאשמים שעלול להעיד לרעת נאשם אחר.¹⁶ יחד עם זאת, חוק סדר הדין הפלילי אינו מפרט מהי חקירה ראשית או מהי חקירה שכנגד ומהן השאלות המותרות במסגרת כל חקירה. הסעיף היחיד בחוק סדר הדין הפלילי ממנו ניתן להסיק בוודאות עילה להתנגדות, הן לנוסח שאלה והן לתוכן התשובה, הוא סעיף 163 לחוק האוסר לשאול נאשם שבחר להעיד במסגרת חקירה שכנגד על עניין הנוגע להרשעותיו הקודמות, מלבד אם העיד על אופיו הטוב או הביא ראייה אחרת לכך. בהמשך לכך, הסעיף היחיד בחוק אשר ממנו ניתן ללמוד כי ניתן כלל להתנגד לשאלה הוא סעיף 119 (ב) לחוק, העוסק בסדרי גבייתת של עדות מוקדמת.

מעבר לחוק סדר הדין הפלילי, שאינו מספק הכוונה רבה, הסעיף העיקרי המשמש במשפט הישראלי כעילה לביסוס התנגדויות הוא סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957, הקובע כי:

"בחקירת עד בבית משפט, לא ירשה בית המשפט חקירה אשר, לדעת בית המשפט, אינה לענין הנידון, ואינה הוגנת, ובפרט לא ירשה בית המשפט חקירה שיש בה משום עלבון, הפחדה, התעיה או ביוש שאינם לענין הנידון ואינם הוגנים."

לטעמי, סעיף זה הוא סעיף דיוני המתייחס בעיקר לנוסח השאלה ופחות לשאלת קבילות התשובה. אני לומד זאת ממיקומו של הסעיף - כחלק מן החוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) ולא חלק מפקודת הראיות או מכל חקיקה ראייתית אחרת, וכן מניסוחו של הסעיף - שאינו דן כלל בסוגיית קבילות התשובה, אלא קובע איסור לחקור בסוגיות מסוימות ובאופנים מסוימים, כחלק מכללי ניהול המשפט.

סעיף 2 לאותו חוק, שכותרתו "חקירת נפגע בעבירת מין", אוסר על הצגת שאלות בדבר עבר מיני לנפגע עבירת מין אלא אם בית המשפט קבע שהדבר עלול לגרום לנאשם עיוות דין.¹⁷ גם כאן, לטעמי, האיסור העיקרי הוא על נוסח שאלה שכן אין התייחסות מפורשת בחוק לקבילות התשובה.¹⁸

15 סעיף 174 לחוק.

16 סעיפים 178 עד 180 לחוק, בהתאמה.

17 לסעיף מקביל אך מפורט בהרבה בכללי הראיות הפדראליים ראו: FRE Rule 412. Sex-offense Cases: The Victim's Sexual Behavior or Predisposition.

18 וראו לעניין זה עמדתו של כבוד השופט נ' הנדל בע"פ 9468/10 פלוני נ' מדינת ישראל, (נבו, 16.4.12), פסקה 2 לחוות דעתו.

19 דיון יחסית ארוך בשאלת ההתנגדות (וחרגי בנוף הספרות המשפטית הישראלית) ניתן למצוא ב' בן אור, 'י' משייקר ו-ס' לובט, **אמנות הפרקליטות: כיצד חושבים על ניהול משפט**, כרך שני (הוצאת נבו, 2000), 69-115. חסרונם העיקרי של דיון זה הינו היותו תרגום לעברית של חלק מספר אמריקני על ניהול משפט בפני מושבעים (Modern Trial Advocacy). לטעמי, לא נעשה מאמץ של ממש במהלך התרגום להתאים את הדיון שבו למשפט הישראלי, בו מתנהלים דיונים בפני שופט מקצועי אשר משמש גם כקובע העובדות וגם כמכריע בסוגיות משפטיות, כגון שאלת קבילות הראיות. לטעמי אף לא נעשה מאמץ של ממש לבסס את האמור בו על הדין והפסיקה בישראל. בנוסף, הספר אינו מכיל פירוט רב לגבי סוגי ההתנגדויות ומשמעותן ומתרכז יותר בשאלה כיצד מתנגדים ומתי.

20 ראו לאחרונה דיון בשאלה בעלת מאפיינים דומים המשלבת דיני ראיות וסדר דין פלילי במאמרו של א' לייסט, "להגיש" (אמרת עד תביעה שנחקר בחקירה נגדית כדי להצביע על סתירות בין האמרה במשטרה לעדות בבית המשפט) או לא להגיש? זוהי השאלה", **הסינוור** 209 (2014), 4.

21 מולר וקירקפטר, לעיל הערה 9, בעמ' 586-587.

22 במשך שנים רבות לא היו במשפט האמריקני כללי ראיות החקוקים בצורת קודקס מקיף. דיני הראיות פותחו בדרך הנהוגה במדינות המשפט המקובל, בפסיקת בית המשפט, וסוגיות מעטות בדיני ראיות זכו לחקיקה אד הוק. בשנת 1965 מונתה ועדה מיעצת על ידי נשיא בית המשפט העליון הפדראלי דאז, ארל וורן,

מעבר לסעיפי החוק המעטים הדנים בהתנגדויות, הפסיקה והספרות המשפטית¹⁹ כמעט ולא עוסקת בשלב חקירת העדים, על ההתנגדויות שבו, למרות חשיבותו הרבה לגילוי האמת. ייתכן והדבר נובע מן העובדה כי החלטות הנוגעות להתנגדות לשאלה הן הכרעות דיוניות קצרות בדרך כלל, שקשה לתקוף בהליך הערעור, במיוחד לאור הכלל הקובע כי אין ערעור על החלטות ביניים בפלילים.²⁰

לעומת הדין הישראלי, הדין אמריקני הפדראלי כלל לא מעגן את סדר המשפט ואין במסגרתו התייחסות לא לפרשת התביעה או פרשת ההגנה ולא לסדר חקירת העדים במסגרת. עניינים אלה אינם מעוגנים בכללי סדר הדין הפלילי הפדראליים (Federal Rules of Evidence, (להלן "FRE"), אך למרות זאת, סדר הבאת העדים והראיות הנהוג ברוב מדינות ארה"ב דומה מאוד לזה המעוגן במסגרת חוק סדר הדין הפלילי הישראלי.²¹ אף על פי כן, כלל 611 ל-FRE²² מבסס את רוב העילות להתנגדויות שאינן נוגעות לתוכן הראייה. סעיף זה קובע כי:

"Mode and Order of Examining Witnesses and Presenting Evidence

(a) CONTROL BY THE COURT; PURPOSES. The court should exercise reasonable control over the mode and order of examining witnesses and presenting evidence so as to:

- (1) make those procedures effective for determining the truth;
- (2) avoid wasting time; and
- (3) protect witnesses from harassment or undue embarrassment.

(b) SCOPE OF CROSS-EXAMINATION. Cross-examination should not go beyond the subject matter of the direct examination and matters affecting the witness's credibility. The court may allow inquiry into additional matters as if on direct examination.

(c) LEADING QUESTIONS. Leading questions

להתנגד לשאלות רחבות מידי, גם בנימוק כי "השאלה מעורפלת" (Vague), במיוחד אם השאלה אינה ברורה דיה ולא ניתן להבין ממנה מה מבקש השואל לדעת.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? על פניו נראה כי הנהוג המשפטי בישראל הוא הפוך מהנהוג האמריקאי ולפיכך נראה כי התנגדות זו אינה מתאימה לשימוש בישראל. לעיתים קרובות החקירה הראשית של עד בבתי המשפט בישראל מורכבת משאלות בודדות בלבד והעד במידה רבה מספר את סיפורו בצורת נרטיב חופשי. לפי התרשמותי, נראה כי עדות שכזו גם נתפסת לעיתים כמהימנה יותר מאשר עדות הנדרשת לשאלות רבות על מנת להתקדם. ייתכן שדרך תחקור שכזאת בחקירה ראשית אינה חכמה במיוחד, שכן היא מאפשרת לעד לסטות לכיוונים לא רלוונטיים וייתכן שאף לא קבילים, אך עניין זה נתפס בדרך כלל כסיכון של הצד שהביא את העד ובחר לתשאל אותו כפי שבחר ולא כעילה להתנגדות כלשהי. גם במסגרת החקירה הנגדית, אמנם נראה כי אין זה נכון במיוחד לשאול עד של הצד שכנגד שאלות פתוחות ורחבות המבקשות תשובה נרטיבית, אך טקטיקה שכזו בחקירה נגדית אינה נתפסת כדבר אסור או כעילה להתנגדות ואם צד החוקר נגדית מעוניין לנקוט בה - הדבר נתפס כחלק מזכותו לחקור נגדית כפי שהוא מוצא לנכון.

2. ארגומנטטיבי (Argumentative)
כלל, מטרתן של השאלות המוצגות לעד במהלך חקירתו על ידי מי מן הצדדים היא לקבל מן העד מידע הקביל כראייה במשפט, כאשר לרוב מדובר במידע שהעד קלט בחושיו שלו. לאחר גביית העדויות, במסגרת הסיכומים, רשאי כל אחד מן הצדדים במשפט להסיק מסקנות מן המידע שניתן במהלך העדות, לאפיין את העדות כמהימנה או כלא מהימנה, כמוגזמת, כהיגיונית או כלא היגיונית, להצביע על חוסר עקביות בעדות, סתירות פנימיות או סתירות לראיות אחרות, ועוד.
מהותה של ההתנגדות "ארגומנטטיבי" היא שהצד החוקר אינו שואל את העד שאלה של ממש אלא טוען טיעון שמקומו בסיכומים. חקירת העד לא נועדה כדי לבסס את המסקנות שצד מבקש להסיק מן העדות או להעיר על מהימנות העד או ההיגיון או חוסר ההיגיון שבעדות. התנגדות זו יכולה וצריכה לבוא לא רק כאשר הצד החוקר טוען או מסכם ממש מבלי לשאול שאלה, אלא גם כשהצד החוקר מסווה כשאלה טענה שמקומה בסיכומים. כך לדוגמה, השאלה "איך זה יכול להיות שעשית את כל הפעולות שהעדת עליהן עכשיו בפרק זמן של שלוש שניות בלבד?" צריכה להיפסל על בסיס היותה ארגומנטטיבית, שכן מדובר בטענה

should not be used on direct examination except as necessary to develop the witness's testimony. Ordinarily, the court should allow leading questions: (1) on cross-examination; and (2) when a party calls a hostile witness, an adverse party, or a witness identified with an adverse party."

בדומה לסעיף 2 לחוק לתיקון סדרי דין, כלל 611 קובע כי על בית המשפט להגן על עדים מפני הטרדה או ביוש שאינו ראוי. בניגוד לדין הישראלי, כלל 611 קובע כי על בית המשפט ליישם שליטה סבירה בדרך חקירת העדים, כדי שההליך יהיה אפקטיבי לקביעת האמת וכדי למנוע בזבז זמן שיפוטי (סמכות זו מעוגנת בישראל בעיקר בפסיקה). עוד קובע הסעיף כי החקירה הנגדית לא תחרוג מן הנושאים שעלו בחקירה הראשית ולנושאים הנוגעים למהימנות העד, עניין שנדון בו בהרחבה בהמשך.

יצוין כי גם בדין האמריקני ישנה פסיקה מועטה יחסית בנוגע להתנגדויות הנוגעות לנוסח השאלה, וזאת משום שאף שם מדובר בהחלטות דיוניות קצרות הניתנות במסגרת ההליך בערכאה הדיונית ואשר קיים קושי מובנה לתקוף אותן בערכאות הערעור.

ההתנגדויות המוכרות במשפט האמריקני (שאינן לתוכן הראייה)²³ והשימוש האפשרי שלהן במשפט הישראלי

1. שאלה רחבה או שאלה המבקשת תשובה נרטיבית (Broad Question or Calls for a Narrative Answer)
ההנחה הבסיסית של חקירת עד על דוכן העדים היא שהחוקר שואל שאלות והעד עונה תשובות לשאלות שנשאל. ניתן לאפשר לעד להעיד בצורה של נרטיב חופשי ובתי משפט בארה"ב לא פסלו עדויות מן הסוג הזה בלבד, כך שנראה כי לבית המשפט יש שיקול דעת בעניין זה. על אף זאת התפישה המקובלת היא כי עדות בדרך של שאלה-תשובה היא עדיפה. עדות שכזאת הוגנת יותר לצד שכנגד, שכן השאלות רומזות אם התשובה שתבוא היא בלתי קבילה או עלולה להשפיע השפעה לא נאותה על המושבעים. בנוסף, עדות בדרך של שאלה-תשובה נתפסת כמקצועית יותר ועלולה להזיק פחות לצד החוקר אשר הולך עם העד עקב בצד אגודל.²⁴ לכן קיימת עילת התנגדות לשאלה רחבה מידי או לשאלה אשר מבקשת מהעד תשובה נרטיבית, דהיינו שאלה שהיא הפוכה מן השאלה המנחה. ניתן לומר כי שאלה שכזו היא שאלה מבלבלת בהיותה שאלה כללית מידי שאינה מספקת הנחייה טובה מספיק לעד לגבי הנדרש ממנו כדי לספק תשובה. לכן, נהוג לעיתים

על מנת לנסח טיוטה של קודקס ראיות כללי לבתי המשפט הפדראליים. באותה תקופה היו רק שתי מדינות בהן נחקקו כללי הראיות בקודקס מקיף, קליפורניה וניו ג'רזי. בהליך חקיקה מורכב ביותר ולאחר תיקונים משמעותיים של הקונגרס, נחקקו לבסוף כללי הראיות הפדראליים ונכנסו לתוקף ב-1 ליולי 1975, ומאז הם מתוקנים ומעודכנים מעת לעת. חקיקת כללי הראיות הפדראליים הביאה לתנופה של חקיקת כללי ראיות דומים (אך לא זהים) ברוב מדינות ארה"ב (מולר וקירפטרין, לעיל הערה 9, בעמ' 3-6). למרות זאת, לא ניתן לדבר על "דיני הראיות בארה"ב" שכן אין כאלה. לכל מדינה דיני ראיות שונים במעט מרעותה. ברשימה זו אשתמש במודל של דיני הראיות הפדראליים כמקור ההפניה העיקרי לדיני הראיות בארה"ב, לאור מעמדו המשפיע וכקודקס המשקף ברובו, את הדין במרבית המדינות בארה"ב.

23 למעט במקומות בהם צוין אחרת, התבססתי בחלק זה של הרשימה בעיקר על:

C. Park and R. D. Friedman, Evidence Cases and Materials (12th Ed. 2013) 68-77 (להלן: "פארק ופרידמן").

במסווה של שאלה. השואל בעצם טוען שהעד משקר ושלא יכול היה לבצע את סדרת הפעולות עליהן העיד בפרק זמן כה קצר ולכן מקומה של טענה כזו היא בשלב הסיכומים ולא כחלק מהחקירה. גם שאלה כגון "האם אתה באמת מצפה שנאמין למה שאמרת עכשיו?" אינה שאלה של ממש, כלומר מטרתה אינה לקבל מן העד מידע שקלט בחושיו, אלא לטעון שהעד אינו מהימן.²⁵ טיעון שכזה מקומו בסיכומים.

בשאלות שהן ארגומנטטיביות יהיה בדרך כלל אלמנט וכחי או תוקפני כלפי העד, ולכן לעיתים נהוג להתנגד לשאלות אלה כשאלות המטרידות את העד בהתאם ל-FRE Rule (3) (a) 611. זהו חוסר הבנה של מהות ההתנגדות. הבעיה האמתית בשאלה אינה שהיא לא נוחה לעד, שאחרת כל שאלה שאינה נוחה לעד תיפסל וכך יישמט הבסיס לחקירה נגדית בכלל. הבעיה בשאלה היא שהשואל מקדים את המאוחר, הוא אינו שואל באמת שאלה אלא מסכם וזמן הסיכומים טרם הגיע.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? הבסיס להתנגדות זו, כלומר האבחנה בין שלב העדויות ומטרתו לבין שלב הסיכומים ומטרתו, קיים בוודאי גם בדין הישראלי.²⁶ בנוסף, הדין הישראלי מכיר בכך כי הערכת מהימנותם של עדים הוא עניין שבית המשפט הוא המוסמך היחיד להחליט בו,²⁷ ולכן נראה שאין מקום לשאול עדים שאלות כגון "למה שנאמין לך?". לאור זאת, לדעת הכותב ניתן וצריך להתנגד לשאלות אשר במסגרת המשפט האמריקני יוכרו כארגומנטטיביות, גם בישראל. שאלות שהן במהותן טיעון מוסווה שמקומו בסיכומים בהחלט יכולות להיחשב גם כשאלות שאינן הוגנות במסגרת סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים). ברור שאין להתנגדות זו כדי למנוע מן החוקר לעמת את העד עם סתירות או פירוט העולות מעדותם של עדים אחרים או מנתונים אובייקטיביים, דבר שהוא בבסיסה של כל חקירה נגדית ראויה.

3. נשאל ונענה (Asked and Answered)

להתנגדות זו יש שני מופעים שונים אפשריים, כאשר לשני המופעים נפקות הפוכה. בעוד הראשון הוא התנגדות לשאלה, השני הוא התנגדות להתנגדות. המופע הראשון הוא התנגדות לשאלה חוזרת שכבר נשאלה ונענתה לגוף העניין על ידי העד. שאלה שכזו נראה כי צריכה להיפסל מכוח סמכותו של בית המשפט למנוע בזבוז זמן.²⁸ לעיתים

התנגדות זו מכונה גם התנגדות לראיות כפולות או מיותרות (Cumulative). עם זאת, יש בהתנגדות האמורה גם בעיתיות מסוימת. מצד אחד, מהותה של חקירה נגדית היא ללחוץ על העד בשאלות אשר הן לעיתים שאלות חוזרות, בניסוחים שונים, על מנת לעמוד על מהימנותו ודיוק עדותו. אין לצפות שצד החוקר נגדית יקבל את תשובתו הראשונה של העד לכל עניין שנשאל. אם נרשה זאת, העד ילמד במהרה שהוא יכול להתחמק משאלות קשות על ידי הכחשות קצרות כאשר החוקר לא יכול להמשיך ולחקור בעניין זה. מן הצד השני, אנו לא רוצים לאפשר לצד לחקור את העד בשאלות חוזרות עד כדי הטרתו והתשתו כך שיתן את התשובה שהחוקר מבקש לשים בפיו. לכן, נראה כי האיזון המתאים הוא שכאשר צד קיבל תשובה עניינית לשאלתו וקיבל הזדמנות נאותה לחקור את העד על תשובה זו כדי לחשוף שקרים, טעויות או אי דיוקים, עליו לעבור הלאה לנושא הבא.²⁹ אם הדבר לא נעשה, ניתן להתנגד בעילה זו של "נשאל ונענה".

המופע שני של ההתנגדות הוא כאמור בעל משמעות שונה לגמרי. הוא מגיע כתשובה להתנגדות לנוסח השאלה כאשר העד כבר השיב. כפי שציינתי למעלה, התנגדות לנוסח השאלה, כאשר התשובה קבילה, כבר אינה רלוונטית אם העד הספיק להשיב לשאלה בטרם הושמעה ההתנגדות. לכן, אם מושמעת התנגדות לנוסח השאלה מאוחר מידי והעד כבר הספיק להשיב תשובה קבילה, התשובה להתנגדות צריכה להיות "נשאל ונענה" במובן זה שהעד כבר השיב לשאלה ולכן ההתנגדות דינה להידחות.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? לדעת הכותב בוודאי שכן. אמנם, בניגוד לאמור בכללי הראיות הפדראליים אין בישראל מקור חוקי המעגן סמכותו של בית המשפט להגביל חקירתו של צד החוקר עד מטעם של בזבוז זמן, אך סמכות זו מעוגנת היטב בהלכה הפסוקה.³⁰ הדבר נכון במיוחד לגבי שאלות חוזרות³¹ או כדברי בית המשפט העליון בעניין דג'אני³² "שאלות שכבר נשאלו וניתנה להן תשובה".

גם למופע השני של ההתנגדות, כתשובה להתנגדות לנוסח שאלה שהושמעה באיחור, הנוהג בישראל זהה לזה האמריקני ואם ניתנה כבר תשובה קבילה, ההתנגדות נמחקת לאחר מתן התשובה. במצב זה, כל שנותר הוא להכריע בשאלת המשקל שיש לתת לתשובה האמורה לאור השאלה הלא ראויה.³³

24 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, בעמ' 590-589, 592-593.

25 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, בעמ' 591.

26 חוק סדר הדין הפלילי, סעיפים: 156, 157, 159, 164, 167, 169.

27 סעיף 53 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971.

28 בהתאם ל-FRE 611 (a) (2).

29 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, עמ' 591.

30 קדמי, בעמ' 1571-1573, וההפניות שם.

31 ע"פ 6253/04 דהרי נ' מדינת ישראל (נבו, 26.4.07), פסקה 24.

32 ע"פ 5329/98 דאג'ני נ' מדינת ישראל, (נבו, 2.3.03), פסקה 4.

33 קדמי, בעמ' 1561 ובעמ' 1600.

לשואל את התשובה אשר השואל מבקש לקבל. לעיתים נהוג לומר כי שאלה המבקשת תשובה של "כן או לא" היא שאלה מנחה. זוהי כמובן טעות. שאלה השואלת עד ראייה לאירוע האם ראה מה קרה מבקשת תשובה של "כן או לא" אך אינה מנחה את העד בתשובה הרצויה לשואל.³⁷ גורמים רבים יכולים להפוך שאלה לשאלה מנחה. נראה ברור כי שאלה תהייה מנחה באם היא מתחילה או מסתיימת בבקשה לאישור אמרה של השואל, כגון "האם נכון ש...", "תאשר לי בבקשה ש...". כך גם שאלה אשר מנוסחת כך שתוביל לאפשרות אחת ברורה בעוד שאר האפשרויות מעורפלות, כגון "אתה הבנת שאתה אמור להיפגש עם הנאשם בביתו בשעה עשר בערב, או משהו כזה?" מן הצד השני, שאלה המנוסחת כך שהיא מציעה לעד שתי תשובות אפשריות מבלי להנחות אותו איזו תשובה היא רצויה, יכולה להיחשב כשאלה שאינה מנחה, כגון "האם אתה התקשרת אליו או הוא אליך?". לעיתים ניסוח השאלה יאמר מעט וההקשר הוא החשוב לקביעה האם השאלה היא שאלה מנחה. אם נאשם עומד לדין באשמת תקיפה וקו ההגנה שלו הוא שלא הרים ידו על הקורבן, שאלה המגיעה מטעם ההגנה לעד ראייה (שהוא עד הגנה), השואלת "האם ראית את הנאשם מכה את הקורבן?" תיחשב כנראה כשאלה שאינה מנחה, בעוד שאם אותה השאלה תופנה על ידי התובע (לעד תביעה) היא בוודאי תיחשב שאלה מנחה. במקרים מסוימים ההנחיה שבשאלה יכולה לבוא משפת גוף, מטון הדיבור ומחיתוכו. כל אלה יכולים להפוך שאלה המנוסחת כשאלה שאינה מנחה לשאלה מנחה.

בניגוד לחקירה הראשית, שאלות מנחות מותרות ורצויות במסגרת חקירה נגדית שם החסרונות של שאלות אלה הופכים ליתרונות בידי הצד שכנגד, החוקר עד שאינו מזדהה עם מטרותיו.

למרות הכלל האוסר על שאלות מנחות במסגרת החקירה הראשית, ישנם מספר חריגים בהם מותר יהיה לצד החוקר את עדיו בחקירה ראשית לשאול שאלות מנחות. שאלות מנחות מותרות במסגרת חקירת העד על סוגיות רקע ועניינים שוליים, שאינם יורדים ללב המחלוקת בתיק.³⁸ שאלות מנחות מותרות גם במסגרת שאלת מעבר מנושא חקירה אחד לשני, וכן בחקירתו הראשית של עד שהוא עד עוין או עד המזוהה עם הצד שכנגד. במקרה האחרון, אין סכנה של ממש שהתשובות המוצעות לעד שכזה ישפיעו על עדותו לטובת השואל שהוא יריבו או עוין אותו.³⁹ שאלות

4. שאלות מנחות (Leading)³⁴ בהתאם ל-FRE Rule 611(c), שאלות מנחות³⁵ אסורות במסגרת החקירה הראשית, למעט במקרים בהם הדבר נחוץ לפיתוח עדותו של העד. בית המשפט ירשה לשאול שאלות מנחות בחקירה נגדית או כאשר צד מזמן עד עוין, צד שכנגד, או עד המזוהה עם הצד שכנגד.

מדוע אסור לצד החוקר עד בחקירה ראשית לשאול את עדו שאלות מנחות? עד נחקר בחקירה ראשית על ידי הצד שהזמין אותו לעדות כאשר ההנחה היא שהוא ידידותי למדי לפחות כלפי הצד שהזמין אותו להעיד לטובתו. לאור זאת, הייתה לצד המזמין הזדמנות להיפגש עם העד בטרם עדותו ולעבור יחד אתו על העדות שאמורה להימסר. במסגרת הכנה זו, נחשף העד על פי רוב לשאלות שהוא עומד להישאל והוא מוסר את תוכן עדותו לצד המזמין. במקרה כזה, כאשר הצד החוקר יודע מה עומד העד להשיב לכל שאלה שישאל, אין צורך בשאלות מנחות אשר יכוונו את העד. מעבר לכך, מכיוון שהעד יודע מדוע הוזמן להעיד ועל מה הוא יתבקש להעיד ובהינתן היותו ידידותי לצד המזמין, עלולות שאלות מנחות להשפיע על עדותו השפעה לא ראויה. חקירת עד באמצעות שאלות מנחות בחקירתו הראשית מעלה שלושה סיכונים נוספים אשר הם נגזרות של הסיכון להשפעה לא ראויה. ראשית, שאלות מנחות עלולות ליצור זיכרון מוטעה של האירועים ובכך להשפיע מבלי משים על העדות. שנית, שאלות מנחות עלולות לדחוף את העד לידי התשובות המוצעות בשאלה מכוח הנוחות בלבד. חווית העדות היא חוויה מלחיצה ובית המשפט מהווה סביבה פורמלית, ציבורית ומאיימת. לכן, עדים עלולים לשאוף לסיים את החוויה הלא נעימה במהירות האפשרית ולענות לעורך הדין של הצד שזימן אותם את התשובות שהוא מנחה אותו לעברן בשאלותיו. הדבר עלול לנבוע גם מחוסר ההבנה של מעמד העדות. אדם המורגל בשיחה חברית אינו מצפה שכל טעות או אי דיוק בדבריו יהיו בעלי משמעות. בדרך כלל סתירות, אי דיוקים או הגזמות עוברים ללא תגובה בשיחה רגילה ואין להם חשיבות מיוחדת, אך לא כך בעדות בבית המשפט. שלישית, שאלות מנחות עלולות להוביל את העד לדלג על פרטים חשובים בעדות, אשר אינם נוחים לצד שזימן אותו לעדות.³⁶

מכאן שניתן וצריך להתנגד לשאלה מנחה כאשר היא מגיעה שלא במסגרת החריגים האמורים בכלל. אך מהי שאלה מנחה? סיווג שאלה כשאלה מנחה אינו עניין קל ופשוט. ההגדרה המקובלת לשאלה מנחה היא שאלה המציעה

34 פרק זה מבוסס בעיקר על 19-20 (Mueller and Kirkpatrick, Evidence Under the Rules: Text, Cases, and Problems 7th ed. 2011) ועל פארק ופרידמן, עמ' 14-15.

35 בחרתי להשתמש ברישומה זו במונח "שאלות מנחות" כתרגום למונח Leading Questions שכן הרגשתי שהוא נאמן יותר למקור. הספרות המשפטית הישראלית הדנה בדיני ראיות מכנה את אותן השאלות "שאלות מדריכות". המהות זהה.

36 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, עמ' 598.

37 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, עמ' 599.

38 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, עמ' 601.

39 מולר וקירקפטריק, לעיל הערה 9, עמ' 600.

מנחות אף מותרות כאשר עד נותן תשובות מפתיעות, במיוחד כאשר עד סותר הודעה כתובה או עדות קודמת שלו בהליך מקדמי. בנוסף, שאלות מנחות יכול שיהיו מותרות כאשר מדובר בעד עם הבנה מוגבלת, כגון ילד, אדם המוגבל בשכלו, או להבדיל, אדם המתקשה בשפה בה נערך ההליך וכן לעד שמיצה את יכולת הזיכרון שלו לגבי האירוע אך נראה שלא מסר את כל המידע הרלוונטי שעליו נקרא להעיד.⁴⁰ שאלות היפותטיות המוצגות לעיתים לעדים מומחים יכולות אף הן להיות בצורה של שאלות מנחות. האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? התשובה לכך היא בוודאי שכן. אמנם בישראל אין הגדרה חקוקה לגבי מתי ניתן להשתמש בשאלות מנחות ומתי לא, אך הכללים בישראל, בהיותה חלק ממדינות המשפט המקובל, קרובים מאוד לכללים הנהוגים בארה"ב. במסגרת החקירה הראשית אסורות ככלל שאלות מנחות, כאשר ההגדרה לשאלות מנחות זהה להגדרה שהובאה לעיל, וזאת למעט חריגים הדומים לחריגים שהובאו לעיל מן המשפט האמריקני, כגון עד עוין, עד הסותר הודעה בכתב, ריענון זיכרון וכאשר הדבר נחוץ לפיתוח העדות.⁴¹

5. חקירה נגדית מעבר לתחום הראשית (Cross Examination Beyond the Scope of Direct) בהתאם ל-FRE Rule 611 (b) החקירה הנגדית מוגבלת לנושאים שעלו בחקירה הראשית ולנושאים אשר קשורים למהימנות העד. בית המשפט רשאי לאפשר לעד לחקור לגבי נושאים נוספים בדרך של חקירה ראשית. מכאן, כאשר צד מבקש לחקור עד בחקירה נגדית ובמיוחד בשאלות מנחות על נושא שהוא רלוונטי אך לא עלה בחקירה הראשית ולא קשור למהימנות העד, שאלה זו צריכה להיפסל מן הטעם של חריגה מתחום הנושאים שעלו בחקירה הראשית. האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? נראה שהתשובה לשאלה זו היא לא. ראשית, בישראל אין כלל המגביל את החקירה הנגדית לנושאים שעלו בחקירה הראשית. כל נושא שהוא רלוונטי להליך או קשור למהימנות העד הוא נושא שמותר לחקור עליו בחקירה נגדית ונראה שיש הצדקה טובה לכך. שנית, בניגוד למשפט האמריקני בו לצד שכנגד יש את הזכות (ויש אף האומרים את החובה המקצועית) לראיין את עדי הצד שכנגד בטרם חקירתם בבית המשפט,⁴² עורך הדין

הישראלי מוגבל על ידי כלל 37 לכללי האתיקה⁴³ האוסר ככלל על מגע עם מי שעומד להעיד מטעם הצד שכנגד בנושא הקשור לעדותו. בנוסף, במשפט הישראלי התקבלה פרשנות מרחיבה ביותר לגבי עבירת הטרדת עד,⁴⁴ כך שכל מגע עם עד פוטנציאלי של הצד שכנגד, בטרם הפך לעד, במהלך המשפט ולאחר שכבר העיד, בידי עורך הדין עצמו או בידי מי מטעמו, עלול להוות עבירה פלילית.⁴⁵ לאור הבדל משמעותי זה, ברור מדוע קובעים כללי הראיות הפדראליים כי החקירה הנגדית מוגבלת לנושאים שעלו בחקירה הראשית, או לנושאים הקשורים למהימנות העד בלבד. מטרת החקירה הנגדית היא להעמיד במבחן את עדותו של העד אותה מסר בחקירה הראשית. כאשר לצד שכנגד הייתה הזדמנות לראיין את העד בטרם עדותו, נראה כי אין מקום לאפשר לו לנצל את החקירה הנגדית, על שאלותיה המנחות, כדי לפתח נושאים שלא עלו בחקירה הראשית ולא קשורים למהימנות העד. נושאים אלה, שלגביהם משמש העד של היריב כעד זה פקטו מטעמו של הצד החוקר, ניתן לפתח בדרך המקובלת של חקירה ראשית, ללא שאלות מנחות. שונים הדברים בתכלית כאשר לצד להליך אין כל אפשרות לבוא במגע עם עדי הצד השני. במקרה כזה הצד שכנגד אינו יכול לברר לחול העד, טרם המשפט, האם יש לו מידע העשוי להועיל לו ולשקול אם יש מקום לחזור על שאלות אלה גם בחקירתו בבית המשפט. לאור המגבלה המשמעותית הזו המוטלת על עורך הדין הישראלי, ברור מדוע יש לאפשר לו לחקור עדים אלה במסגרת החקירה הנגדית, בשאלות מנחות, בנושאים רלוונטיים, הגם שאלה לא עלו בחקירה הראשית ואינם משליכים על מהימנות העד.

6. מניח עובדה שאינה בראיות (Assumes a Fact Not in Evidence) שאלה המניחה עובדה שאינה בראיות היא שאלה אשר מכילה בתוכה אמרה על עובדה, שעדיין לא הוצגה כראייה, במסגרת שאלה על עובדה אחרת. לדוגמה, נניח שעורך דין חוקר עדה המציינת שהיא נפלה על הרצפה. העדה טרם אמרה כיצד נפלה על הרצפה. לכן, שאלה כגון "האם כאשר החלקת על קליפת הבננה, נפלת על גבך?" תהייה שאלה המניחה עובדה שאינה בראיות. השואל מציג בשאלתו עובדה כמוכחת, למרות שהעד לא העיד עליה כלל. לכן,

40 מולר וקירקפטר, לעיל הערה 9, עמ' 601-602.
41 קדמי, 1560-1569, 1596-1599. כאמור, קדמי נוקט בלשון "שאלות מדריכות" ולא שאלות מנחות, אך המהות זהה.
42 א' אליגון-דר, "על זכותו וחובתו של הסניגור לשוחח עם עדי התביעה", **הסניגור** 42, (ספטמבר 2000), 4. ראו גם Clark, Dekle and Bailey, Cross-Examination Handbook: Persuasion, Strategies and Techniques, (2011), 248-247 (להלן: "קלארק, דקל וביילי"), וכן: ABA Criminal Justice Section Standards: Defense Function, Part IV Investigation and Preparation, ניתן לצפייה: http://www.americanbar.org/publications/criminal_justice_section_archive/crimjust_standards_dfunc_blk.html#4.1.
43 כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו-1986.
44 סעיף 249 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
45 ע"פ 526/90 **בלזר נ' מדינת ישראל**, פ"ד מה (4) 133 (1991), ע"פ (מחוזי ת"א) 71115/01 **וולדמן נ' מדינת ישראל**, (נבו, 16.7.2002), רע"פ 6989/05 **בני סלע נ' מדינת ישראל**, (נבו, 20.5.2009).
46 ראו: ABA Model Rules of Professional Conduct rule 3.4(e), הניתן לצפייה ב- http://www.americanbar.org/groups/professional_

מדובר בהתנגדות שהיא לא רק לנוסח השאלה, אלא בעיקר לתזמון ורצף. אם העדה הייתה מעידה טרם השאלה כי נפלה מכיוון שהחליקה על קליפת בננה לא היה כל פגם בשאלה. בנוסף, לא היה כל פגם בשאלה אם החוקר היה שואל קודם לכן "האם נפלת מכיוון שהחלקת על קליפת בננה?" והעדה הייתה מאשרת עובדה זו.

השאלה ברת התנגדות כי היא מבלבלת ומטעה את העד. בהינתן מצב עובדתי בו העדה לא החליקה על קליפת בננה, תשובה מדויקת לשאלה צריכה להיות "אכן נפלתי על גבי, אבל לא החלקתי על קליפת בננה." אך העדה עלולה בהיסח הדעת לענות "כן" כאשר הכוונה היא אישור החלק השואל לגבי הנפילה על הגב ולא החלק לגבי מדוע נפלה. ההנחה היא שהעד אינו צריך להיות על משמר על מנת להכחיש הנחות על עובדות שלא העיד עליהן אשר מובאות כחלק משאלות על עובדות אחרות. על השואל לשאול שאלה נפרדת על כל עובדה רלוונטית.

לאור זאת מדובר בהתנגדות אשר עיקר המשקל שלה הוא בעובדה שהשאלה עלולה להטעות את העד מכיוון שהיא מציגה לו עובדה שטרם הוא העיד עליה או טרם עלתה במשפט בצורה אחרת, תוך הנחה שהיא נכונה. אין בהתנגדות זו כדי למנוע מן הצד החוקר לעמת את העדה עם אמרות של עדים אחרים, שטרם העידו בבית המשפט, כל עוד לחוקר יש בסיס ראוי להצגת השאלה⁴⁶ ומדובר בשאלה שאינה מטעה. ההתנגדות אינה להצגת עובדה שטרם הוכחה במשפט עדיין, אלא להצגת עובדה שכזו תוך הצגתה לעד כנכונה או כמוכחת.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? נראה כי התשובה לכך היא כן. הרנון מתייחס להתנגדות זו במפורש בספרו, אם כי הוא מפנה את הקורא לספרות אמריקנית.⁴⁷ אני סבור, כפי שקובע הרנון בספרו, כי שאלה המניחה עובדה שאינה בראיות היא שאלה מטעה ואף עלולה להיות גם שאלה שאינה הוגנת ולכן אסורה לפי סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים).

7. אפיון בלתי נאות (Improper Characterization)
שאלה לוקה באפיון בלתי נאות כאשר במסגרתה עובדה או אמירה של עד מאופיינת על ידי החוקר בצורה לא נאותה. נאמר כי עד העיד זה עתה כי נהג במהירות וכי ייתכן שעבר במעט את המהירות המותרת. שאלה בנוסח "האם נכון שבמסגרת אותה נהיגה פרועה ורשלנית שלך גרמת ל..." תיתקל בשיטה האמריקאית בהתנגדות של אפיון בלתי נאות. העד לא העיד שהוא נהג בצורה פרועה או רשלנית,

ולכן מדובר באפיון לא נאות של העובדה שמסר, שהוא נהג מעט מעל למהירות המותרת. יש לשים לב כי מדובר בהתנגדות הדומה להתנגדות "מניח עובדה שאינה בראיות" במובן זה שמדובר בשאלה מטעה. בהינתן מצב עובדתי בו העד לא נהג בפרעות או ברשלנות תשובה מדויקת מצדו של העד צריכה קודם כל להתנגד לאפיון הלא נאות, "לא נהגתי בצורה פרועה או רשלנית" ורק לאחר להשיב לגוף השאלה. כך שמדובר בשאלה מבלבלת ומטעה. בנוסף, מדובר בשאלה שהיא גם ארגומנטטיבית. אם עורך הדין רוצה לטעון כי העד נהג בצורה פרועה ורשלנית, על סמך המידע שמסר בעדותו, יש לטעון זאת בסיכומים שכן מדובר במסקנה ולא בעובדה שהעד צריך להעיד עליה. התנגדות נוספת מן הסוג הזה היא כאשר החוקר מצטט בצורה מטעה את עדותו של העד (Misstates the Testimony). כך לדוגמה, אם העד העיד שפנה ימינה והחוקר ישאל את העד "כאשר פנית שמאלה..." צריכה השאלה להיפסל עקב הציטוט המוטעה והמטעה של עדות העד.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? גם כאן, כמו בהתנגדות על בסיס הנחה של עובדה שאינה בראיות, נראה כי התשובה חיובית. במסגרת סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) אסורה חקירה המטעה את העד או שאינה הוגנת וניתן לומר כי שאלה המכילה אפיון לא נאות של עדותו היא שאלה מטעה ושאלה שאינה הוגנת. העד עלול להשיב לגוף השאלה ולא להתייחס לאפיון הלא נאות ובכך לאשר אותו במחדל ומבלי משים. מנגד, מדובר בהתנגדות שאינה מעוגנת במסורת של הדיון המשפטי הישראלי. במסגרת חקירה נגדית של עד, יש לחוקר בישראל מרחב פעולה משמעותי וייתכן שבית המשפט יקבע כי אפיון לא ראוי של העדות אינו מטעה או לא הוגן בצורה כזו שיש מקום לפסול את השאלה. לעומת זאת, כאשר מדובר בהפניה או ציטוט מוטעה ומטעה של עדות העד מסגרת השאלה, כאן ברור כי מדובר בשאלה מטעה שדינה להיפסל בהתאם לסעיף 2 האמור.

8. עורך הדין מעיד (Counsel is Testifying)
התנגדות זו היא דרך אחרת לנסח אחת משתי התנגדויות שדנו בהן קודם לכן. לעיתים מדובר בהתנגדות מסוג "מניח עובדה שאינה בראיות", שכן החוקר כולל בשאלתו עובדה אשר אינה בראיות עדיין ובעצם מעיד עליה בעצמו. במקרים אחרים מדובר בהתנגדות "ארגומנטטיבית", כלומר שהסיגור מסכם כעת ולא שואל שאלות עובדתיות לצורך קבלת תשובות עובדתיות. האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? לטעמי בוודאי

responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/rule_3_4_fairness_to_opposing_party_counsel.html. כלל זה קובע כי כל שאלה הנשאלת על ידי צד להליך חייבת להימנע באמונה סבירה כי הנושא רלוונטי ובראיות קבילות. ראו גם קלארק, דקל ו-ביילי, לעיל הערה 42, בעמ' 104-105.

47 הרנון, לעיל הערה 6, בעמ' 94 וההפניות שם.

48 ראו לדוגמה קלארק, דקל וביילי, לעיל הערה 42, בעמ' 85-91.

שכן ומן הנימוקים שהובאו בחלקים הדנים בהתנגדות "ארגומנטטיבי" ו-"מניח עובדה שאינה בראיות".

9. שאלה מורכבת (Compound)

נראה כי גם במסגרת החקירה הנגדית, בה כאמור מותרות שאלות מנחות, אין מקום לשאל שאלות על מספר עובדות בעת ובעונה אחת. שאלה שכזו היא שאלה מבלבלת, שכן העד עלול לענות "כן" או "לא" ואז לא ברור כלל מה אישר העד או מה הכחיש. ייתכן שצד שחוקר עד בחקירה נגדית מעוניין בהכחשה גורפת כדי לעמת את העד לאחר מכן עם עדות סותרת שלו, ולכן הוא מנסה לעמת את העד עם מספר עובדות בו זמנית כדי לקבל הכחשה גורפת. מנגד, יתכן שהחוקר מבקש לקבל אישור, ולכן מציג לעד מספר עובדות במקביל על מנת שאם העד יענה "כן" יוכל לטעון בסיכומים שכל העובדות בשאלה אושרו.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? גם כאן, התשובה המורכבת. רוב החוקרים נגדית לומדים בשלבים מוקדמים יחסית של פעילותם ששאלות מורכבות אינן מומלצות או מועילות במיוחד וספרי הדרכה לחוקרים נגדית ממליצים בדרך כלל להימנע מכך.⁴⁸ נראה כי מן הבחינה הנורמטיבית העמדה הראויה היא שיש להגביל כל שאלה לעובדה אחת. שאלות מורכבות, מעבר להיותם מטעות ולא הוגנות במידה רבה, נוטות לסבך את ההליך ואת ההכרעות העובדתיות בהליך. הכחשתו או אישורו של עד בתגובה לשאלה מורכבת שנשאל עלול ליצור ויכוח מיותר בשלב הסיכומים מה בדיוק הכחיש או מה בדיוק אישר העד מתוך צבר העובדות שהוצגו לו. חוסר בהירות שכזו ניתן לפתור בקלות בקביעה נורמטיבית ששאלה מורכבת אינה שאלה ראויה ודינה להיפסל. מצד שני, בהחלט ייתכן שבית משפט יכשיר שאלות מורכבות, במיוחד במסגרת חקירה נגדית, לאור זכותו של צד לחקור נגדית כפי שהוא מוצא לנכון.

10. מטריד את העד (Harassing the Witness)

הטרדת העד אסורה בהתאם ל- FRE Rule 611 (a) (3). מהי הטרדת עד היא שאלה מורכבת יחסית. ברור שתפקידו של הצד שכנגד החוקר נגדית הוא לשאול שאלות קשות ולהתעקש על קבלת תשובות. הטרדת עד תתרחש רק כאשר החקירה חרגה מגבולות הראוי גם ביחס לחקירה נגדית נמרצת וקשוחה, כגון הטחת עלבונות לא רלוונטיות, או חזרה בלתי פוסקת על שאלות שכבר נענו. התנגדות זו תהייה זהה לעיתים להתנגדות ארגומנטטיבי או להתנגדות נשאל ונענה. האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? בדומה לדעה שהבעתי בחלקים שדנו בהתנגדויות הדומות, ארגומנטטיבי ונשאל ונענה, נראה שגם כאן התשובה לכך היא בחיוב.

סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) קובע כי בית המשפט לא יאפשר חקירה המעליבה או המביישת את העד כל עוד היא אינה לעניין הנדון ואינה הוגנת. לאור זאת שאלה שמטרידה את העד, במובן זה שאינה בגדר שאלה קשה במסגרת חקירה נגדית אלא שאלה המהווה עלבון וביוש ללא כל צורך או רלוונטיות, דינה להיפסל.

11. ספקולטיבי או קורא לעדות סברה (Speculative or Lack of Personal Knowledge)

בהתאם ל-FRE Rule 602 עד כשיר להעיד בעניין בו יש מספיק ראיות לכדי לתמוך בממצא שלעד יש ידע אישי בעניין. ראיות אלה יכולות לבוא מעדותו של העד עצמו. כלומר, הכלל הוא שעד שאינו עד מומחה אמור להעיד רק על עניינים בהם יש לו ידע אישי. בדרך כלל העד יעיד על התרשמות שקלט בחושיו שלו. כך ששאלה אשר קוראת לעד להסיק מסקנה, לספר את דעתו, עמדתו או סברותיו צריכה להיפסל מן הטעם שהיא מבקשת תשובה ספקולטיבית או קוראת לעדות סברה.

האם ניתן להעלות התנגדות זו בישראל? התשובה לכך היא בוודאי כן. הכלל הבסיסי בדיני הראיות במשפט האנגלי-אמריקני, כי עד שאינו עד מומחה מעיד על מה שקלט במו חושיו ויש לו לגבי ידע אישי תקף בישראל בדיוק כפי שהוא תקף בארה"ב, ועדות סברה של עד שאינו מומחה היא בלתי קבילה גם בישראל.⁴⁹ לאור זאת, כל שאלה המבקשת מהעד עדות סברה או כל אמרה אחרת שאינה מבוססת בידע אישי צריכה להיפסל.

סוף דבר

ביקשתי ברשימה זו להציג לעורך הדין הישראלי את ההתנגדויות העיקריות, שאינן התנגדויות לתוכן הראייה, אשר מוכרות במסגרת המשפט האמריקני. בנוסף, בחנתי כל התנגדות והבעתי את דעתי האם מדובר בהתנגדות שניתן לעשות בה שימוש גם בישראל, הן לפי הדין הקיים והן לפני הנוהג המשפטי במסגרת דיונים במשפטים פליליים כפי שזה משתקף בפסיקה בספרות וגם על פי התרשמותי הסובייקטיבית. בסופו של יום עמדתי היא ששאלה לא ראויה צריכה להיתקל בהתנגדות ולהיפסל. פסלותה של שאלה לא ראויה, אינה רק עניין טכני לטעמי, היא עניין מהותי. למרות זאת, משפטים פליליים בישראל דלים בהתנגדויות עד מאוד ואין בישראל תרבות או נוהג מפותח של התנגדויות לשאלות הצד שכנגד. הדבר נובע לטעמי מן העובדה שמשפטים נשמעים בישראל בפני שופטים מקצועיים ולא בפני חבר מושבעים. נראה כי השופטים השומעים משפטים פליליים אינם אוהבים התנגדויות (אגב, בדיוק כפי שחבר מושבעים אינו אוהב

49 י' קדמי, **על הראיות: חלק שני** (מהדורה משולבת ומעודכנת, תש"ע-2009), בעמ' 754-758.
50 ע"פ 116/66 פולק ב' מדינת ישראל, פ"ד כ(3), 393, 398.

על יצר התנצחות זה ולקום ולהתנגד להבאת ראיה פלונית אך ורק אם תהא בהבאתה פגיעה בזכות שולחיהם.”

אם כך הייתה העמדה בשנת 1966 בוודאי כיום, כאשר מבחינה ראייתית המגמה היא מעבר מקבילות למשקל והמגמה הכללית היא התרחקות מפורמליזם משפטי, נראה כי ההתנגדות, הן לשאלות והן לראיות לא קבילות, נתפשת כעניין ארכאי כמעט. אני חולק על תפישה זו. דיני הראיות הם עדיין במהותם דיני הקבילות ונראה כי בשנים האחרונות בית המשפט העליון חוזר להבנה בסיסית זו.⁵¹ לתשובות לא קבילות אין מקום בבית המשפט ואין כל יתרון בכך שהשופט הדן בתיק ישמע אותן, גם אם מקצועיותו הרבה מאפשרת לו להתעלם מהן. גם לשאלות שאינן מנוסחות כראוי אין מקום בבית המשפט. גם כאשר מדובר בשאלות המזמינות תשובות לא קבילות וגם כאשר מדובר בשאלות מטעות, מבלבלות או לא הוגנות. דווקא האחרונות עלולות להיות מסוכנות יותר להליך המשפטי. שאלות אלה עלולות להטעות ולבלבל את העד לתת תשובות שאינן נכונות או אינן מדויקות, אך קבילות כשלעצמן. תשובות שכאלה עלולות להביא לקביעות עובדתיות שגויות או לקביעות מהימנות לא ראיות ואת אלה כידוע קשה ביותר לתקוף במסגרת הליך הערעור.

הסתייגות נוספת שראוי להדגיש בסופה של רשימה זו נוגעת לשאלה המורכבת שעניינה מתי כדאי לצד להתנגד לשאלה ברת התנגדות של הצד שכנגד ומתי כדאי לו להבליג על הפגיעה על מנת לצבור רווחים טקטיים כאלה ואחרים. בסופו של יום שאלה זו מוכרעת בכל תיק ובתיק על עובדותיו ונסיבותיו. רוצה אני לומר שאין לראות ברשימה זו המלצה של הכותב להתנגד תמיד, בכל מקרה שיש עילה להתנגדות. השאלה האם להתנגד לשאלה היא תמיד מורכבת יותר מן השאלה המשפטית האם קיימת עילה להתנגדות.⁵² אך ללא ידע משפטי האם אכן קיימת עילה שכזו, שאלת ההמשך, האם להתנגד, לא יכולה להישאל כלל.

אני מקווה שרשימה זו תהווה תחילתה של פיתוח תרבות התנגדות במשפט הישראלי שיהיה בה לטעמי להגביר את הסיכוי לעשיית צדק בסופו של ההליך המשפטי. ואם לא, אני מקווה לפחות שהיא תעזור למי שטרם לקרוא אותה עד סופה להבין מה בדיוק מהות ההתנגדות אשר מעלה אלישה פלורק בפרק הבא של “האישה הטובה”.

אותן). התנגדויות מפריעות לזרימתו החלקה של ההליך השיפוטי ומשדרות, אולי, שלצד המתנגד יש משהו להסתיר. בעניין זה ניתן להפנות לדברים שנכתבו על ידי בית המשפט העליון לפני זמן רב במסגרת פסק הדין בעניין **פולק**⁵⁰:

”לפחות מחצית הזמן שבית-המשפט הקדיש לדיון במשפט זה, בזבז על-ידי הקטיגור ועל-ידי הסניגורים בהתנגדויות, ובתשובות להתנגדויות, לשאלות אשר העדים השונים נשאלו ולהגשת מסמכים שונים. ...

... אפילו שואל פרקליט את עדו שלו שאלה מדריכה, אין בכך כדי לחייב או להצדיק התנגדות מידית מצד יריבו; אפילו יש בתשובה על שאלה פלונית משום חשש עדות שמיעה, אין בכך בלבד כדי לחייב או להצדיק התנגדות מידית; וכן כל כיוצא באלה. חזקה על השופט היושב לדין שידוע הוא להבחין בין ערכה ומשקלה של תשובה שניתנה על-פי שאלה מדריכה לבין ערכה ומשקלה של תשובה על שאלה כשרה; וכן חזקה עליו שידוע הוא להבחין בין עדות מפי השמועה לבין עדות כשרה; וכל כיוצא באלה. אפילו במקומות אשר בהם מתנהל המשפט הפלילי לפני חבר מושבעים, לא ראינו ולא שמענו כי עורכי-דין יעלו על דעתם להתנגד לכל שאלה מדריכה, ובכל להפסיק את מהלך חקירת העדים על-ידי התנגדויות המוניות ואצלנו, שהמשפט הפלילי מתנהל לפני שופט מקצועי המנוסה והרגיל בכך, בוודאי אין מקום ואין הצדקה להתנגדויות כאלה.

אם יש בהתנגדויות הללו כדי להפסיק את מהלך החקירה של העד, ועל כן להסיח את דעת השופט מגופם של העניינים אשר עליהם הוא מעיד, הרי לגבי בית-המשפט שלרעור מקשים הרישומים של ההתנגדויות והוויכוחים וההחלטות עליהם, על קריאה שוטפת של פרוטוקול העדויות וגורמים לבזבז זמנו ולהסחת דעתו אף של בית-משפט זה. ולא זו בלבד אלא יש בהן, מבחינת הנאשם, משום עינוי הדין, שהרי בלעדיהן אפשר היה לסיים את הדיון במשפט כולו הרבה יותר מהר.

לדעתנו מצחים בתי-המשפט לעמוד על כך כי עורכי-הדין לא ניצלו את הליכי בית-המשפט להתנצחות מיותרת בדיני ראיות, ומצווים עורכי-הדין להתגבר

51 ע"פ 5121/98 **יששכרוב נ' התובע הצבאי**, פ"ד סא(1) 461, ע"פ 1301/06 **אלום נ' מדינת ישראל**, פ"ד סג(2) 177, רע"פ 10141/09 **בן חיים נ' מדינת ישראל**, (נבו, 6.3.12), ע"פ 8704/09 **באשה נ' מדינת ישראל**, (נבו, 11.11.12). ראו גם את פסקי הדין הנדונים במאמרו של א' לייסט, לעיל הערה 20.

52 לדיון בשאלה האם ומתי יש מקום להתנגד כאשר יש עילה ראו אמנות הפרקליטות, לעיל הערה 19, בעמ' 73-79.